

통상임금의 개념적 모호성 해소를 위한 입법정책적 과제

권 혁*

<국문초록>

임금을 둘러싼 노사 간 분쟁의 양상이 바뀌었다. 종래 전형적인 임금분쟁은 임금 책정을 둘러싸고 발생하는 이익분쟁이었다. 지금은 다르다. 유감스럽게도 임금을 더주고 덜주고가 아니라, 법 적용의 모호성으로 인해 발생한 오계산이 분쟁의 원인인 권리분쟁의 형태를 띤다. 문제가 아닐 수 없다. 이러한 식의 분쟁은 입법자가 제대로만 규정해두었다면 애당초 발생하지 않았을 분쟁이기 때문이다. 그래서 통상임금분쟁은 소모적이고 불필요한 분쟁이다. 2024년 12월 대법원 전원합의체 판결은 통상임금에 대해 소정근로의 대가라 보고, 온전한 근로제공이 이루어지는 경우를 사전적으로 가정해야 함을 밝혔다. 단지 재직자 조건과 결부시키면 통상임금 산입범위에서 배제된다는 편법이 계기가 된 판결로서 공감된다. 그럼에도 불구하고 여전히 매끄럽지 않은 대목이 있다. 조건과 결부된 정기상여금 등 금품의 임금성을 명확하게 규명하여야 한다. 이러한 점에서 대법원이 고정성 폐기만으로 통상임금의 개념적 모호성이 완전히 해소되었다고 단정하기도 어렵기 때문이다. 다른 한편 이번 판결에서, 온전한 근로제공을 상정하는 일도 쉽지 않다. 동일가치노동 동일임금원칙은 적어도 통상임금에 관한 한 가장 적극적으로 적용되어야 하는 원칙이다. 통상임금은 노동의 가치를 반영하는 금품이기 때문이다. 기간제 근로계약의 체결시점이나 존속기간이라는 우연한 사정으로 인해 통상임금이 달라지는 일은 없어야 한다. 이런 경우 온전한 근로제공을 어떻게 상정해야 할 것인지는 여전히 의문이다.

통상임금제도의 재정립을 위한 입법적 결단이 이루어진다면 그 방향성은 명확성이어야 한다. 가능한 한 단순하고 계량적이어야 한다. 적어도 오계산 때문에 발생하는 ‘권리분쟁’만큼은 발생하지 않도록 해야 하기 때문이다.

주제어: 임금, 통상임금, 가산임금, 사전확정성, 입법흡결, 상여금, 도구개념

논문투고일자: 2025. 3. 28. 심사일자: 2025. 4. 14. 게재확정일자: 2025. 4. 20.

* 고려대학교 노동대학원 교수, 법학박사

목 차

- I. 서설
- II. 대법원전원합의체 판결에 나타난 통상임금 입법론
- III. 통상임금제도의 입법론적 개편 방안
- IV. 결론

I. 서설

모든 성문법규정은 일반성과 추상성을 가지기 마련이다. 법규범의 구체적인 의미와 내용은 법원의 해석과 적용을 통해 비로소 확인된다. 다만 입법자는 완벽할 수 없다. 법 규정 또한 입법적 흠결(Regelungsleucke)을 내포하기 마련이다. 이 또한 법관의 해석(Rechtsfortbildung)을 통해서 메워지게 된다.¹⁾ 그렇다고 해서 입법자가 입법을 게을리해서는 안된다. 가능한 입법자는 규범적 명확성과 구체성을 최대한 도모해야 한다. 적어도 입법자는 법률을 통해 자신의 가치적 결단(Gesetzgeberische Entscheidung)을 명확히 제시해주어야 하기 때문이다. 자칫 과도하게 모호한 규정을 두거나, 아예 입법흠결을 그대로 방치할 경우 법관에 의한 법해석은 자칫 법형성(Rechtsschaffung)²⁾으로 변질될 수 있음을 염두에 두어야 한다.³⁾

법규정을 해석하는 법원이 자신의 입장을 스스로 변경할 수는 있다. 다만 그 변경이 반복되고, 그 변경된 내용 역시 본질적인 부분에 해당한다면 이는 법규정 자체의 불완전성과 흠결이 있음을 의미하는 것이다. 이러한 경우 입법자는 마땅히 입법적 정비를 서둘러야 한다. ‘통상임금’이 바로 그런 경우다. 최근 대법원은 통상임금에 관한 전원합의체 판결을 통해

1) Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz, 1964, S.39.

2) 법학방법론상 전통적인 법발견(Rechtsfindung) 3 모델에 따르면 1.법해석(Auslegung), 2.법흠결보완(Lückenfüllung), 그리고 3.허용되지 않는 법발견(Unzulässige Rechtsfindung=Rechtsschaffung)으로 구별되어 진다고도 한다(Fischer, ZfA 2002, S.228).

3) Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5.Aufl., 1983, S.410-411.

통상임금 개념의 재정립에 나선 바가 있었다.⁴⁾ 대법원은 동판결에서, 근로기준법이 통상임금의 범위에 대하여 명확한 기준을 제시하지 않고 있으며 근로기준법 시행령의 통상임금 정의규정도 구체적 사안에서 통상임금성을 판정할 수 있는 실천적 판단 기준으로 삼기에 부족한 상황이라는 점을 분명히 밝히면서, “통상임금의 범위를 명확하게 하려는 노력이 법원 판결 등을 통해 이루어져 왔지만, 그러한 판례법리에도 불구하고 고정성과 통상임금 판단을 둘러싼 논란은 계속되었다”라고 하면서, 굳이 법원이 통상임금 개념의 재정립에 나설 수 밖에 없는 이유를 스스로 밝힌 바가 있다.⁵⁾

유감스럽게도 통상임금의 산입범위를 둘러싼 모호성을 판례법리를 통해 해소하는 것은 기대하기 어렵다. 그 이유는 간단하다. 현행 법령 상 통상임금의 개념정의로부터 법원은 결코 자유로울 수 없기 때문이다. 현행 법령상 통상임금의 개념정의에 내재된 추상성과 일반성을 그대로 둔 채, 법원이 단지 ‘해석’(Auslegung)을 통해 도구개념으로서 갖추어야 할 통상임금의 개념적 명확성을 도모하는 일은 처음부터 불가능한 일이었던 셈이다.

입법흡결에 따른 법적 분쟁 등 제반 문제점을 근본적으로 해소하는 방법은 입법이다. 그리고 입법은 법원이 아닌 입법자의 고유한 권한이요 몫이다. 통상임금에 관한 한 입법을 통해 그 개념적 모호성을 해소해야 한다고 평가하는 이유가 실은 여기에 있다. 특히 우리나라 노동현장에서는 야간근로나 연장근로 등이 광범위하면서도 수시로 발생한다. 그런 만큼 총임금에서 가산임금 비중도 크다. 만약 가산임금의 산정이 제대로 이루어지지 않으면 노동법 위반이 된다. 자칫 임금체불에 해당하여 엄격한 형사처벌이 부과될 수도 있다.

4) 통상임금 개념의 재정립에 법원이 나서야 한다고 판단한 자체만 보아도, 우리나라에서 노동에 관한 입법권 행사의 ‘지체’가 가히 심각하다는 것을 손쉽게 짐작할 수 있다.

5) 대법원 2024.12.19. 선고 2020다247190 판결; 대법원 2024.12.19. 선고 2023다302838 판결.

게다가 임금을 둘러싼 분쟁은 노사 간에 더 많은 임금을 얻어내기 위한 전형적인 이익분쟁으로서의 속성을 가지고 있었다. 현재 벌어지고 있는 통상임금분쟁은 다르다. 통상임금 그 자체에 내재된 개념적 모호성 때문에 유발된 분쟁이다. 입법자에 의해 통상임금에 관한 법적 명확성을 구현하였더라면 애당초 발생하였을 리 없는 분쟁이다. 통상임금을 둘러싼 노사 간 갈등과 분쟁을 입법자가 유발하고 있는 셈이다. 통상임금에 관한 개념적 모호성을 더 이상 그대로 방치해서는 안되는 이유도 또한 여기에 있다.

통상임금 등을 비롯한 임금관련법제의 입법정책적 개선방향성은 분명하다. 바로 ‘명확성’(Rechtsklarheit)이다. 이러한 관점에서 통상임금에 관한 입법정책적 대안에 대해 고민해 보기로 한다.

II. 대법원전원합의체 판결에 나타난 통상임금 입법론

1. <도구개념으로서> 통상임금

(1) 내용

통상임금의 개념은 근로기준법에서 명시적으로 사용되고 있다. 하지만 정작 그 개념에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 단지 시행령에서 규정해 두고 있을 뿐이다.

근로기준법령에서 통상임금 개념을 별도로 설정해 두고 있는 이유는 다음 세 가지 때문이다. (i) 첫째, 연장, 야간, 휴일 근로 등이 이루어진 경우 가산임금을 지급하도록 근로기준법 제56조에 규율되어 있는데, 그 가산임금 산정을 위한 기준이 바로 통상임금이다. (ii) 두 번째로는 통상임금은, 근로기준법 상 해고예고수당을 산정하는 기준임금이다.⁶⁾ 그 외에도 (iii) 통상임금은, 평균임금의 최저한이 되는 ‘기준임금’으로서의 기능도

6) 근로기준법 제26조는 다음과 같다.

수행한다.⁷⁾

결국 - 대법원이 적절히 지적한대로 - 통상임금은 그 자체가 독자적 의미를 가지는 것은 아니다. 근로기준법 등에서 정하는 바에 따른 법정수당 산정 등의 기준으로서 기능한다. 법정수당을 지급하자면, 그 수당금액의 구체적 산정을 위해 통상임금이 먼저 확정되어야 하는 것이다.⁸⁾

(2) 비판적 평가

‘도구개념’이란, 그 기능적 ‘수월성’을 염두에 두고 개념 설계되어야 한다. 입법기술적으로 볼 때, 도구개념은 그 법적 당위성은 내피에 불과하다. 외피를 구성하는 개념요소는 매우 계량적이고 구체적이어야 한다. 법적 당위성이라는 내피를 존중하되 그렇다고 해서 법적 당위성에 완벽하게 부합되도록 설계할 필요는 없다. 대표적인 예가 ‘평균임금’이다. 평균임금의 개념적 당위성은, 임금을 통한 근로자의 생활 수준을 가늠하는 데 있다. 평균임금을 산정하는 시점 이전 3개월 동안의 모든 임금을 그 산입 범위로 할 뿐이다. 왜 하필 3개월인가에 대하여는 아무런 설명이 없다. 수

제26조(해고의 예고) 사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

7) 근로기준법 제2조 제1항 제6호에서는 평균임금을 정의하고 있다. 이에 따르면 “‘평균임금’이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 근로자가 취업한 후 3개월 미만인 경우도 이에 준한다.”고 규정되어 있다. 다만 근로기준법 제2조 제2항에서는 “동법 제2조 제1항 제6호에 따라 산출된 금액이 그 근로자의 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 한다”라고 규정하고 있다.

8) 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 판결; 대법원 2024.12.19. 선고 2023다302838 판결.

월성과 명확성을 염두에 둔 입법자의 입법기술적 판단일 따름이다.⁹⁾

도구개념으로서 통상임금도 마찬가지로 여야 한다. 그 제도적 기능과 법적 당위성을 좇아 소정근로대가성, 일률성, 정기성 등의 법개념을 일일이 열거하는 방식은 입법기술적으로 무모한 것이다.¹⁰⁾ 노동현장의 노사 당사자들은 법률가가 아니기 때문이다. 비록 고정성요건을 폐기하였다고 해서 통상임금의 명확성이 확보되었다고 단언하기는 아직 어렵다. 입법기술적 흠은 여전히 잔존한다고 보아야 한다.

2. <강행적 개념으로서> 통상임금

(1) 내용

이번 대법원 전원합의체 판결의 주된 목적은, 이른바 고정성 개념 특히 재직조건부 임금제를 통한 통상임금의 산정범위에 대한 현저한 왜곡을 바로 잡기 위한 데 있다.¹¹⁾

-
- 9) 어쩌면 6개월이나 1년이 당위성 측면에서 더 타당할 수도 있다는 비판이 얼마든지 제기될 수도 있다.
- 10) 근로의 가치를 평가하는 개념이자, 개념의 추상성으로 인해 처음부터 혼선을 피할 수 없다는 견해로는, 이철수, “통상임금에 관한 최근 판결의 동향과 쟁점-고정성의 딜레마”, 서울대학교 법학 제54권 제3호, 2013. 09, 879-880면.
- 11) 대법원 2024.12.19. 선고 2020다247190 판결; 대법원 2024.12.19. 선고 2023다302838 판결: “고정성에 관하여 ‘근로자가 임의의 날에 소정근로를 제공하면 추가적인 조건의 충족 여부와 관계없이 당연히 지급될 것이 예정되어 지급 여부나 지급액이 사전에 확정된 임금은 고정성을 갖춘 것’이라는 일반적인 기준을 정립하고, 세부적인 판단 기준도 임금 유형별로 제시하였다. 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하는 임금(이하 ‘재직조건부 임금’이라 한다)과 일정 근무일수를 충족하여야만 지급하는 임금(이하 ‘근무일수 조건부 임금’이라 한다)은 조건성취 여부가 불확실하므로 고정성이 부정된다는 기준 등이 그것이다. 이는 통상임금의 범위를 명확하게 하려는 노력의 일환이었지만, 그 이후에도 고정성과 통상임금 판단을 둘러싼 논란은 계속되었다. 학계와 실무에서 2013년 전원합의체 판결이 정의한 고정성 개념을 비판하거나 이를 우회하여 통상임금성을 다른 각도에서 판단하려는 시도가 이어져 왔다. 이러한 문제의식과 축적된 논의를 바탕으로 통상임금에 관한 근본적 고찰을 통하여 이 사건 쟁점인 ‘재직조건부 임금’의 통상임금성 문제를 넘어 ‘근무일수 조건부 임금’ 등 고정성이 문제되는 다른 임

2013년 전원합의체 판결이 정의한 고정성 개념은, ‘재직조건부 임금’에 대한 통상임금의 배제 위험성을 내포하고 있었기 때문이다. 요컨대 통상임금을 기초로 하여 가산임금을 지급하도록 하는 것은 근로기준법 상 명시된 강행규정인데, 2013년 대법원 판결에 따른 고정성 개념은 당사자로 하여금 임금항목에 - 사후적으로 비로소 그 성취 여부가 결정되는 - ‘조건’을 부가하면 곧바로 통상임금의 범위를 변경시켜 결과적으로 근로기준법 상 강행규정을 함부로 회피할 수 있도록 만드는 결과를 초래하는 문제점이 있었던 것이다.¹²⁾

마땅히 소정근로의 대가로서 사전에 확정된 통상임금에 해당함에도 불구하고 단지 실제 그 지급여부가 일정한 조건의 성취 여부에 의해 결정되도록 하였다는 이유로 통상임금에서 배제되는 결과를 초래하는 것은 잘못이라고 본 것이다.

(2) 비판적 평가와 입법정책론적 시사점

근로기준법은 근로조건에 관한 강행규범이다. 이를 위반하는 근로계약을 체결할 경우, 그 내용은 무효가 되고(강행효), 근로기준법 등에 정한 바에 따른 근로조건내용이 근로계약의 내용이 된다(직물효). 통상임금도 또한 마찬가지이다. 통상임금을 기초하여 가산임금을 산정하도록 규정해 두고 있다.

문제는 통상임금의 기준임금으로서의 입법기술적 적격성이 흠결되었다는 데 있다. 통상임금은 노사가 합의로서 정해 둔 고유한 임금지급체계를 바탕으로 하여 가산임금에 산입될 임금을 선별해내야 한다. 이는 매우 어

금 유형까지 정합성 있게 규율할 수 있는 통상임금 개념을 제시할 필요가 있다.”

12) 이에 대해 대법원은 “2013년 전원합의체 판결은 근로관계 당사자가 어떤 임금 항목에 조건을 부가하여 그 지급 여부와 지급액이 사전에 확정될 수 없는 경우 고정성이 결여되어 통상임금이 아니라는 법리를 제시하였다. 이로써 당사자가 강행적 성격을 가지는 통상임금의 범위를 쉽게 좌우할 수 있게 허용하는 결과가 발생하였다. 사용자가 우월적 지위에서 임금에 조건을 부가함으로써 통상임금의 범위를 부당하게 축소할 위험도 초래하였다(대법원 2024.12.19. 선고 2020다247190 판결; 대법원 2024.12.19. 선고 2023다302838 판결)”라고 설명하고 있다.

려운 일이 될 수 밖에 없다. 노사가 합의로서 정해둔 임금체계란 조건도 결부될 수 있을 뿐만 아니라 그 지급시기와 방식과 내용이 다양하고 복잡할 수 있기 때문이다. 그래도 문제될 일은 거의없다. 노사가 합의했기 때문이다. 오로지 문제가 있다면, 합의한대로 지급되지 않을 때 비로소 발생한다.

통상임금을 법정 기준임금으로 설계해 둔 입법자는, 유감스럽게도 노사 간 합의로서 정해 둔 복잡한 임금체계를 전제로 해서 통상임금범위가 확정되도록 하였다. 복잡한 임금체계 상 개별 지급 금품의 성격을 일일이 규명하여 통상임금 산입여부를 분별해내도록 하는 것은 처음부터 무모한 일이다. 이러한 입법방식은 기준임금이자 도구개념으로서 통상임금의 규율방식으로는 타당하지 않음을 방증하는 것이다.¹³⁾ 오히려 통상임금이 기준임금으로서 강행적 효력을 가지도록 하기 위해서는 일률적이고 최저 기준으로서의 속성을 가지도록 해야 한다.

근로기준법의 강행규정으로서의 속성 상 통상임금도 마찬가지로 강행적 성격을 가지는 것임은 당연히 받아들일 수 밖에 없으면서도 웬지 - 외국의 입법례에서와 같이 - 노사 간 합의가 배제되는 것이 어색하게 느껴지는 이유가 실은 여기에 있다.

3. <가상임금으로서> 통상임금

(1) 내용

우선 소정근로란, 근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하기로 정한 근로를 말한다. 즉, 소정근로란 1일 8시간, 1주 40시간 등 법정근로시

13) 최저임금법 상 최저임금은 다르다. 사업장 또는 근로자마다의 개별성과 다양성에도 불구하고 최저임금은 획일적으로 정해진다. 원칙적으로 사업장 규모는 물론 직무나 생산성 등에 상관없이 모든 근로자에게 적용되는 기준이기 때문이다. 다른 한편 평균임금도 기준임금이자 도구개념이다. 평균임금은 ‘사후적으로’ 지급된 임금을 산입범위로 한다는 점에서 사전적인 가상개념으로서 통상임금 보다는 기준임금으로서 입법기술적 모호성이 덜한 편이라고 할 수 있다.

간 범위에서 근로관계 당사자 사이에 정한 근로시간 즉 소정근로시간에 통상 제공하기로 한 근로이다.¹⁴⁾

소정근로의 대가란, 소정근로에 관하여 대가로서 사용자와 근로자가 미리 지급하기로 약정한 금품을 말한다.¹⁵⁾ 통상임금은 - 그 제도적 기능을 염두에 둔다면, ‘소정근로’의 가치를 온전하게 담아내야 한다. 이때 소정근로의 가치는, - 대법원 전원합의체 판결에서 실시한 바와 같이 - 사후적으로 확정되는 실근로 여부와는 무관하다. 따라서 법정 기간 동안 근로자에게 실제 지급된 임금의 총액을 기초로 하여 사후적으로 산정되는 평균임금과 통상임금은 구별된다. 요컨대 통상임금은 근로자가 ‘소정근로를 온전하게 제공하는 경우’를 전제로 그 지급이 예정된 ‘가상의’ 임금을 말하는 것이고(가상개념으로서 통상임금성), 해당 근로자가 근로를 실제로 제공함에 따라 수령하는 ‘실제임금’과는 구별된다.

만약 ‘실제임금’의 변동성이 가상임금으로서 통상임금의 개념범위결정에 영향을 미친다면, 자칫 가상임금이자 도구개념으로서 통상임금의 본질을 훼손할 수도 있다는 이번 대법원 전원합의체 판결의 지적은 일리가 있다. 원래 통상임금의 고정성 요건은 근로기준법 시행령 상 통상임금 정의에 명시된 바가 없다. 동시행령에 따르면, (i) 소정근로의 대가성 (ii) 정기성 (iii) 일률성에 관하여 규정하고 있을 뿐이다.

하지만 판례는 이미 오래 전부터 통상임금의 개념 해석론을 통해 이른바 통상임금의 개념요소로서 ‘고정성’ 요건을 인정해오고 있었는데, 예컨대 대법원은 1978년 10월 10일자 판결에서도 오늘날 현행 판례와 마찬가지로 “소정근로 또는 총 근로의 대상으로 근로자에게 지급되는 금품으로서 그것이 정기적·일률적으로 지급되는 것이면 원칙적으로 모두 통상임금에 속하는 임금이라 할 것이나, 근로기준법의 입법 취지와 통상임금의 기능 및 필요성에 비추어 볼 때 어떤 임금이 통상임금에 해당하려면 그것

14) 노동법실무연구회(최은배, 성준규 집필부분), 『근로기준법 주해 I』 제2판, 박영사, 2020, 314면; 임종률, 『노동법』 제19판, 박영사, 2019, 414면.

15) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

이 정기적·일률적으로 지급되는 고정적인 임금에 속하여야 하므로, 정기적·일률적으로 지급되는 것이 아니거나 실제의 근무성적에 따라 지급 여부 및 지급액이 달라지는 것과 같이 <고정적인 임금이 아닌 것>은 통상임금에 해당하지 아니한다”¹⁶⁾고 판시하였던 바가 있었다.

이러한 대법원 판결에도 불구하고 1982년 근로기준법 시행령을 새로 개정하는 과정에서도 통상임금의 정의는 종전과 동일하게 고정성을 별도로 명시하지 아니하였다. 이러한 사실은 통상임금의 개념에 있어 고정성 요건은 별도의 독자적 개념요소라기 보다는 <소정근로의 대가로서의 속성>에 내포되어 있는 것에 그친다는 것을 이미 입법자가 인식하고 있었음을 보여주는 것이라고 볼 수 있다.

[시행 1982. 8. 13] [대통령령 제10898호, 1982. 8. 13, 일부개정]
제31조 (통상임금의 정의) ①법과 이 영에서 “통상임금”이라 함은 근로자에게 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액·일급금액·주급금액·월급금액 또는 도급금액을 말한다.

예컨대 6개월에 한번씩 정기적으로 지급되는 정기상여금이 있고, 그 정기상여금의 지급조건은 그 지급시점에서 재직중이어야 한다고 하자. 비록 그 정기상여금지급에 조건이 결부되어 있더라도 금품의 속성이 소정근로의 대가로서 임금이라면 사후적으로 해당 근로자가 그 조건을 충족하였는지 여부와 상관없이 통상임금성을 인정하여야 한다는 것이 판례법리이다. 근로의 온전한 제공이란, 마땅히 그 지급시점에서 재직중으로서 근로를 제공하고 있는 경우를 가상으로 전제하여야 한다고 본다. 근로자라면 마땅히 정기상여금 지급 시점에서도 재직하면서 소정 근로를 제공할

¹⁶⁾ 대법원 1978. 10. 10. 선고 78다1372 판결; 대법원 1994. 10. 28. 선고 94다26615 판결; 대법원 2002. 7. 23. 선고 2000다29370 판결; 대법원 2003. 4. 22. 선고 2003다10650 판결; 대법원 2012.3. 29 선고 2010다91046 판결 등.

것이 사전적으로는 충분히 예상된다. 오히려 그 지급시점에서 재직 중이 아니라고 하는 사정이야말로 이례적이고 우연적인 사후결과에 불과하다고 보아야 한다.

요컨대 통상임금은, 소정근로가 온전하게 제공‘되었다’는 것이 아니라 온전하게 제공 ‘될 것’임을 염두에 두고 그 지급을 약정해 둔 임금을 말한다.

(2) 비판적 평가와 입법정책적 과제

통상임금의 가상개념으로서의 속성은 통상임금의 법적 기능과 의의에 비추어 볼 때 매우 중요한 의미를 가짐에 틀림없다. 이번 판례가 실시하고 있는 바와 같이, 가상개념으로서 통상임은, 온전한 근로제공의 경우를 가정한 임금이라는 뜻이다.¹⁷⁾

문제는 그 근로제공의 온전성 개념이 다시금 사전확정되지 아니하면 본래 통상임금의 도구로서의 기능을 수행하기 곤란하다는 데 있다. 온전한 근로의 제공의 내용이 사전에 어느 정도 명확하게 확정되어야 하지만, 현실적으로 이러한 근로의 온전성을 확정하는 일은 결코 쉽지 않다. 나아가 고용형태에 따라 동일노동 동일임금원칙이 훼손되어서는 안된다. 통상임금은 온전한 근로제공이 있음을 전제로 하여 산정된 노동력의 가치를 보여주는 개념이다. 고용형태에 따라 온전한 근로제공의 내용이 달라 질 수 있으며, 이 경우 동일가치노동임에도 동일임금이 책정되지 못하는 논리적 모순이 발생할 수 있다.

예컨대 재직조건부 정기상여금을 1년에 1번 지급하는데, 그 지급시점이 12월인 경우를 가정해 볼 수 있다. 기간의 정함이 없는 정규직 근로자인 경우라면, 온전한 근로제공의 경우를 가정한다면 마땅히 12월에도 근로를 제공할 것임을 전제하여야 한다. 이것이 이번 대법원의 판례법리이다. 만약 기간의 정함이 있는 근로자로서 11개월동안만(1월부터11월말일까지) 근로를 제공하기로 합의된 기간제 근로자라면 근로제공의 온전성

17) 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결.

에 대한 평가가 달라지게 된다. 해당 기간제 근로자가 11월에 근로관계가 종료되지 않고 12월까지 근로를 계속할 것임을 전제할 수는 없기 때문이다. 마땅히 12월말에 지급하는 재직조건부 정기상여금은 통상임금에서 배제해야 한다. 만약 정규직 근로자와 비정규직 기간제 근로자 간의 업무 내용이 완전히 동일하다면, 고용형태에 따라 가산임금산정기준이 달라지는 문제가 발생하게 된다. 이는 잘못이다.

일률성은 그 임금이 소정근로의 대가인 임금임을 뒷받침하는 개념적 징표이다. ‘일률적’으로 지급되는 것에는 ‘모든 근로자’에게 지급되는 것뿐만 아니라 ‘일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자’에게 지급되는 것도 포함된다.¹⁸⁾ 이때 ‘일정한 조건 또는 기준’은 통상임금이 소정근로의 가치를 평가한 개념이라는 점을 고려할 때, 작업 내용이나 기술, 경력 등과 같이 소정근로의 가치 평가와 관련된 조건이라야 한다.¹⁹⁾ 비록 소정근로의 가치평가와 관련된 조건은 일률적으로 동일함에도 ‘기간의 정함’ 여부나 ‘근로계약의 존속기간’이라는 사정에 의해 통상임금이 달라지는 결과가 초래되는 셈이다.

결론컨대 통상임금을 실근로 또는 실제임금과 분리되도록 하는 것이 법문에 부합하고 소정근로의 가치도 온전하게 반영하는 방식임을 지적하였다는 점에서 이번 대법원 전원합의체 판결은 큰 의의를 가진다. 그럼에도 불구하고 소정근로제공의 온전성 개념에 관한 개념적 모호성은 여전히 잔존하고 있는 있는 셈이다.

18) 통상임금의 개념을 둘러싸고 판례법리가 변화해 온 것은 고정성만이 아니다. 일률성도 마찬가지이다. 초기 판례에서는 일률성 요건에 대하여 ‘전체 근로자’에게 지급되는 것을 의미하는 것으로 보았다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93다31979 판결; 대법원 2003. 4. 22. 선고 2003다10650 판결). 이후 법원은, 그 입장을 변경하면서, 비록 사업장 내 모든 근로자에게 일률적으로 지급되는 것은 아니더라도, 일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자에게 지급되는 것이면 일률성이라는 개념 요소를 충족한 것으로 보고 있다(대법원 2011. 8. 25. 선고 2010다63393 판결; 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다22061 판결).

19) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.

4. <연장근로 등 억제수단으로서> 통상임금

(1) 내용

이번 전원합의체 판결에서 대법원은, 통상임금 개념을 연장근로 등의 억제라는 근로기준법의 정책 목표에 부합하도록 설계하고 해석하여야 한다는 입장을 명확히 하였다. 종래 대법원은 가산임금의 기능적 의의를, 근로자의 인간다운 생활을 보장하기 위하여 연장근로 등을 억제함은 물론 연장근로 등의 가치에 상응하는 금전적 보상을 해 주려는 데에 그 취지가 있음을 밝혀 온 바가 있었다.²⁰⁾ 이러한 해석은, 연장근로 등은 근로자에게 더 큰 피로와 긴장을 주고 근로자가 누릴 수 있는 생활상의 자유시간을 제한하므로, 근로기준법은 연장근로를 제한하는 규정을 두면서(법 제53조) 연장근로 등에 대해 통상임금의 50% 이상을 가산한 임금을 지급하도록 하는 점(법 제56조)에 주목한 것이다.

(2) 비판적 평가 및 입법정책적 과제

가산임금제도가 연장근로를 제한하는 것만을 정책적 기능으로 평가하는 것은 과도한 측면이 있다. 연장근로 등의 제한에 실효적으로 기여하는 것이 가산임금을 낮추는 것이 효과적일지, 가산임금을 높이는 것이 효과적인지를 판단하는 것은 쉽지 않기 때문이다. 그럼에도 불구하고 명확한 것은, 연장 근로 등 비통상적인 근로에서 초래되는 피로와 긴장 등을 충분히 반영하도록 함으로써 그 노동의 부담에 상응하는 합당한 보상이 이루어지도록 해야 한다는 점이다. 근로시간의 양적 단축이 노동정책에 있어 중핵적 과제임에 틀림없지만, 대법원이 법 해석을 함에 있어 이러한 노동정책적 평가와 방향성을 고려하는 것이 타당한지는 여전히 의문이다. 이는 오히려 입법자의 고유한 역할 영역이요, 그들의 몫이다.

²⁰⁾ 대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도15393 판결 등.

Ⅲ. 통상임금제도의 입법론적 개편 방안

1. 통상임금의 개념에 관한 연혁론적 검토

(1) 1953년 제정 근로기준법 상 평균임금과 통상임금

1953년 근로기준법 제정 당시에는 평균임금에 관한 정의규정을 두고 있었을 뿐(동법 제19조) 통상임금의 정의규정은 별도로 두고 있지 않았다.²¹⁾ 단지 동법 제46조 상의 시간외휴일근로에 관한 가산임금 지급 의무를 명시해 두면서, 그 기준으로 ‘통상임금’이라는 용어를 사용하고 있을 따름이었다.

1953년 제정 근로기준법

제19조(평균임금의 정의) 본법에서 평균임금이라 함은 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3월간에 그 근로자에 대하여 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총근로일수로 제한 금액을 말한다. 취업 후 3월 미만도 이에 준한다.

제46조(시간외휴일근로) 사용자는 연장시간근로(第42條, 第43條의 規定에 依하여 延長된 時間의 勤勞)와 야간근로(下午10時부터 上午6時까지의 사이의 勤勞)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 지급하여야 하며 휴일근로(本法에서 定한 賃金支給休日의 勤勞)에 대하여는 사용자는 당해일에 소당임금을 지급하는 것을 이유로 본법에서 정한 휴일에 지급할 임금의 지급을 거절할 수 없다.

21) 같은 취지로 방강수, “통상임금 법리의 이원화(二元化) — 가산임금 외의 ‘다른 수당’ 산정시의 통상임금 법리 —” 법학논총(한양대) 제36권 제4호, 2019, 한양대 법학연구소, 261면 이하 참고.

통상임금의 개념이 본격적으로 문제가 되기 시작한 것은 1970년 후반에 이르러서였다. 당시 판례는 통상임금의 개념을, 평균임금의 산정과는 달라서 “실제 근무일수나 실제 수령한 임금에 구애됨이 없이 고정적이고 평균적인 ‘일반임금’, 즉 기본임금과 이에 준하는 고정적으로 지급되는 수당의 1일 평균치를 말한다.”²²⁾고 해석하였다. ‘통상임금’의 개념요소로서 고정성은 사후적으로 비로소 확정될 수 있는 ‘실제’근로나 ‘실제’임금과 대비되는 고정적인 일반임금이 가지는 속성을 의미하는 것이었다.

(2) 시행령 상 통상임금의 개념 정립

통상임금의 개념은, 1982년 근로기준법 시행령을 개정하면서 비로소 법령에 명시되었다.²³⁾하면서 통상임금에 관하여 명시하게 되었다.²⁴⁾

근로기준법 시행령(1982년)²⁵⁾

제6조(통상임금)

- ② 이 법과 이 영에서 “통상임금”이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.

22) 대법원 1978. 10. 10. 선고 78다1372 판결.

23) 대통령령 제10898호, 1982. 8. 13, 일부 개정.

24) 하경호, 임금법제론, 2013, 80면.

25) 1997년에 다음과 같이 개정되었다(대통령령 제15320호, 시행 1997. 3. 27.).

1997년 3. 27일 시행 근로기준법 시행령

제6조(통상임금)

- ① 법과 이 영에서 “통상임금”이라 함은 근로자에게 정기적·일률적으로 소정 근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액·일급금액·주급금액·월급금액 또는 도급금액을 말한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 통상임금을 시간급금액으로 산정할 경우에는 다음 각호의 방법에 의하여 산정된 금액으로 한다.
1. 시간급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액

흥미로운 사실은, 이때 통상임금의 개념을 시행령에 신설하면서도 정성과 일률성 그리고 소정근로의 대가성 외에 고정성에 대해서는 아예 명시하지 않았다는 점이다. 그럼에도 불구하고 고정성은 그 후로도 법원에 의해 일관되게 지지되었다.²⁶⁾

(3) 소결: 평균임금의 기능적 한계와 그 보완을 위한 도구로서의 통상임금

연혁적으로 보면 통상임금은 평균임금의 기능적 한계를 극복하기 위해 마련된 개념임을 알 수 있다. 근로기준법 제정 당시 입법자는 (사후적 개념으로서) 평균임금을 정의내리되, 실제 근로제공이 이루어질 수 없었던 근로자를 염두에 두고, ‘통상임금’ 개념을 사용하고자 하였던 것이다.

‘실제로’ 근무하고 난 이후에 ‘실제로’ 지급된 임금을 기준으로 산정되는 평균임금개념은, 특별한 사정으로 인해 근로를 제공하지 못한 근로자에 대한 보호에는 전혀 기능할 수 없었던 개념적 한계가 있었기 때문이

2. 일급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 1일의 소정 근로시간 수로 나눈 금액
 3. 주급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 주의 통상임금 산정기준시간수(법 제20조의 규정에 의한 주의 소정근로시간과 소정근로시간외의 유급처리되는 시간을 합산한 시간)로 나눈 금액
 4. 월급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 금액을 월의 통상임금 산정기준시간수(주의 통상임금산정 기준시간에 1년간의 평균주수를 곱한 시간을 12로 나눈 시간)로 나눈 금액
 5. 일·주·월외의 일정한 기간으로 정하여진 임금에 대하여는 제2호 내지 제4호에 준하여 산정된 금액
 6. 도급금액으로 정하여진 임금에 대하여는 그 임금산정기간에 있어서 도급제에 의하여 계산된 임금의 총액을 당해 임금산정기간(임금마감일이 있는 경우에는 임금마감기간을 말한다)의 총근로 시간수로 나눈 금액
 7. 근로자가 받는 임금이 제1호 내지 제6호에서 정한 2이상의 임금으로 되어 있는 경우에는 각 부분에 대하여 제1호 내지 제6호에 의하여 각각 산정된 금액을 합산한 금액
- ③ 제1항의 규정에 의한 통상임금을 일급금액으로 산정할 때에는 제2항의 규정에 의한 시간급 금액에 1일의 소정근로시간수를 곱하여 계산한다.

26) 대법원 1991. 6. 28. 선고 90다카14758 판결; 대법원 1994. 10. 28. 선고 94다 26615 판결; 대법원 2002. 7. 23. 선고 2000다29370 판결 등

다. 당초 예정된 바에 따른 온전한 근로제공을 하였다면 지급되었을 ‘가상의’ 임금(=통상임금)을 평균임금의 최저기준으로 사용하고자 한 것이다.

2. <온전한 근로의 제공>으로서 ‘소정 근로’의 개념

(1) 적정임금의 산출과 노동력의 가치평가

근로계약을 체결함에 있어 노사 간에 임금에 대한 합의는 필수다. 기본적으로 근로계약당사자들은 근로제공에 대한 보수의 책정(Bemessung der Arbeitsvergütung)은 자유로운 합의의 대상이다. 다만 임금균등지급의 원칙(Grundsatz der Lohngleichheit)이나 최저임금법에 따른 제한 그리고 단체협약에 따른 임금협정이 노사 간 자유계약의 한계일 따름이다.²⁷⁾

최저기준을 상회하는 소위 ‘적정한’ 임금은 자격증 보유 여부나 직무 성격 등 해당 근로자의 ‘노동력’에 대한 고유한 시장 가치를 종합적으로 고려하여 결정된다(Gesamtbewertung).²⁸⁾ 통상 그 노동력의 시장가치는 ‘시간 당’ 가치로 환산된다. 임금은 근로 ‘시간’의 양으로 산정됨이 원칙이기 때문이다.

(2) <온전한 근로의 제공>이 가지는 법적 의의

임금은 근로제공의 대가이다. 노동력의 가치는 통상적인 상황에서의 근로제공을 전제로 하여 산정된다. 이때 통상적인 상황이란, 현행 근로기준법 상 법정 근로시간 즉, 1일 8시간, 1주 40시간 범위 내에서의 근로제공 상황임을 의미한다. 다른 한편 야간근로에 대해서는 별도의 가산임금이 지급되도록 하고 있다. 그렇다면 통상적 상황에서의 근로제공이란, 야간이 아닌 ‘주간’, 휴일이 아닌 ‘평일’에 이루어지는 근로제공을 의미함을 알 수 있다.

그 외에 근로제공의 통상성을 가늠하게 하는 법정 지표는 없다. 예컨대

²⁷⁾ 이러한 범위에서 임금의 수준은 내용통제(Inhaltskontrolle)를 받을 따름이다.

²⁸⁾ BAG 14.7.1966 AP Nr. 24 zu §612 BGB; 14.5.1969 AP Nr. 25 zu §612 BGB.

월 단위 또는 연단위의 법정 기준은 별도로 명시되어 있지 않다.²⁹⁾ 그렇다면 그 이외의 통상적 상황은 노사가 합의한 바에 따른 근로의 제공임을 의미하는 것으로 보아야 한다.

3. 통상임금에 관한 노사 합의의 존중 필요성

(1) 독일 가산임금제도와 비교법적 검토

독일민법 제611조a에서는 근로계약을 “사법적 계약관계(privatrechtlicher Vertrag)로서 그 주된 급부내용을 노무제공으로 하며, 그에 대한 금전적 대가로서 지급하는 계약”이라고 정의하고 있다.³⁰⁾

다만 독일은, 연장근로나 야근근로 등을 제공한 경우 이에 대한 대가로서 임금은 가산임금이 지급되기 마련이지만 그렇다고 해서 가산임금지급이 법적 의무로 규정되어 있지는 않다. 단지 단체협약에 정하는 바에 따라 가산임금이 지급될 따름이다. 이는 단체협약의 적용을 받지 않는 근로자의 경우에도 마찬가지이다. 단체협약에서 정해 놓은 임금협정내용은 해당 업무 종사 근로자의 노동가치를 합리적으로 평가하는 지침으로서 기능하기 때문이다.³¹⁾

이처럼 독일은, 가산임금 지급여부나 그 가산율 등에 대해 강행법적 규율을 두고 있지 않다. 그 대신 단체협약을 통해 노사의 자율적 합의에 따

29) 물론 통상임금은 임금 책정이 새로 이루어지는 시점에서 새로 노동력의 가치로서 재산정되어야 할 것이다. 만약 임금을 3년 단위로 새로 책정하기로 하였다면, 그 근로계약 체결 시점에서 책정된 노동력의 가치를 반영해야 한다. 결과적으로 이 경우 ‘통상임금’은 3년을 단위로 한 온전한 근로의 제공을 전제로 하여 미리 산정된 노동력의 가치라고 할 수 있다.

30) BAG Urt. v.25.2016-5 AZR 135/16, BeckRS 2016, 69232 Rn. 32.

31) 독일에서는 임금지급에 있어 해당 임금의 산정이 합리적인 수준에 이르지 않는 등 계약상의 공정성에 반하는가 여부를 민법 상 평가할 때(독일민법 제138조 제2항) 그러한 단체협약 상의 임금 규정 내용이 고려된다. 이때 노무제공(Arbeitsleistung)의 관행(Verkehrssitte), 그리고 노무제공의 범위와 그 지속기간, 그리고 노무의 정기적인 제공 여부나, 근로제공의무자의 노동력제공에 있어 적격성이나 완전성 등이 고려된다.

르도록 한다.³²⁾

(2) 평가

1) 적정임금과 적정노동력가치의 결정메커니즘의 동일성

적정임금은 노사 간 단체협약을 통해 자율적으로 결정된다. 가산임금 역시 마찬가지여야 한다. 임금의 적정성은 단체협약으로 정할 수 있지만 노동력 가치의 적정성은 그리 할 수 없다는 것은 논리적이지 않다. 가산임금 결정에 관한 메커니즘이 적정임금결정 메커니즘과 근본적으로 달리 취급되어야 할 이유는 없기 때문이다.

2) <최저통상임금> 개념의 구축

근로조건의 최저 기준이 근로기준법에 마련되어 있음을 염두에 둔다면, 연장, 야간, 휴일에서의 근로제공에 대한 최소한의 대가 기준을 마련해 둘 필요는 분명 있다. 그 기능적 의미를 고려한다면, 최저임금 개념을 차용하는 방안을 모색해 볼 만하다. 최저임금은, 개별 근로자의 직무, 자격 중 보유 여부, 학력 등 구체적 제반 사정과 상관없이 일률적으로 정해 진다. 게다가 금액으로 고시된다. 이와 마찬가지로 최저통상임금을 야간근로의 억제 등 노동정책적 목표를 염두에 두고, 금액으로 정해 두는 방안을 고려할 필요가 있다.

다만 개별 사업장 또는 업무의 속성 등을 감안한 ‘적정’ 통상임금은, - 최저통상임금을 상회하는 범위 내에서 - 노사가 단체협약 등을 통해 정할 수 있도록 하는 것이 타당하다. 현행 근로기준법은 적정통상임금을 강행법률로서 근로기준법에 규율해 둔 셈이다. 이례적인 규율방식이 아닐 수 없다. 단체협약 등 노사 간 합의를 통해 통상임금산정범위 등을 미리 정해 둔다면 적어도 통상임금의 모호성을 둘러싼 소모적 법률분쟁만큼은 분명 예방할 수 있다.

³²⁾ Scharb/Linck, ArbR-Hdb, §69 Rn. 11(박지순, 이상익, 통상임금의 이해, 2013, 39면 이하 재인용).

IV. 결론

1. 임금을 둘러싼 노사 간 분쟁의 양상이 바뀌었다. 종래 전형적인 임금분쟁은 임금 책정을 둘러싸고 발생하는 이익분쟁이었다. 지금은 다르다. 유감스럽게도 임금을 더주고 덜주고가 아니라, 법 적용의 모호성으로 인해 발생한 오계산이 분쟁의 원인인 권리분쟁의 형태를 띤다. 문제가 아닐 수 없다. 이러한 식의 분쟁은 입법자가 제대로만 규정해두었다면 애당초 발생하지 않았을 분쟁이기 때문이다. 그래서 통상임금분쟁은 소모적이고 불필요한 분쟁이다.

1-1. 더 큰 문제는 이러한 분쟁이 앞으로도 반복될 수 있다는 점 때문이다. 판례를 통한 분쟁의 예방은 더 이상 기대하기 어렵게 되었다. 대법원이 제시한 법리의 적용을 장래효로 제한한 것도 이례적이거니와 고정성 폐기만으로 법적 모호성이 완전히 해소되었다고 단정하기도 어렵기 때문이다. 이쯤되면 입법자가 직접 나서야 한다.

2. 2024년 12월 대법원 전원합의체 판결은 통상임금에 대해 소정근로의 대가라 보고, 온전한 근로제공이 이루어지는 경우를 사전적으로 가정해야 함을 밝혔다. 단지 재직자 조건과 결부시키면 통상임금 산입범위에서 배제된다는 편법이 계기가 된 판결로서 공감된다. 그럼에도 불구하고 여전히 매끄럽지 않은 대목이 있다. 온전한 근로제공을 상정하는 일도 쉽지 않기 때문이다. 특히 기간의 정함이 있는 기간제 근로자의 경우와 같이 고용형태에 따라 근로제공의 온전성에 대한 판단이 달라질 수 있다. 이는 고용형태와 상관없이 동일가치노동에 대해서는 동일임금이 지급되어야 한다는 원칙에 부합하지 않는다. 동일노동동일임금원칙은 노동력의 가치를 반영하는 통상임금개념에 가장 적극적으로 부합되어야 한다.

2-1. 현행 통상임금제도는 입법기술적 흠결이 크다. 강행규정으로서 최

저기준을 규정해 둔 것임은 분명하지만, 그 산정의 토대는 정작 노사 간 합의의 산물인 (적정)임금이다. 적정임금을 도출하기 위해 노사는 단체교섭 등을 통한 합의를 하면서 임금지급과 관련하여 매우 다양한 방식과 조건, 지급시기를 설정해 두기도 한다. 적정임금은 그래서 복잡하다. 이렇듯 지급조건과 지급 범위 그리고 지급시기 등이 매우 복잡하게 얽혀 있는 임금체계로부터 다시금 소정근로의 대가와 일률성, 그리고 정기성을 밝혀 최저기준으로서 통상임금을 산정해내는 것은 처음부터 무모한 일이다. 논리적으로 본다면, 적정임금을 노사 합의로 정하였다면, 가산임금 역시 노사합의로 정하는 것이 맞다. (적정)임금은 노사가 자율적으로 매우 다양하고 복잡하게 설계할 수 있도록 해 놓고, 가산임금은 그 적정임금 중에서 소정근로대가성과 일률성, 정기성을 기준으로 선별해내라는 것은 처음부터 기대하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 대법원은 일관되게 근로기준법의 강행규정성을 들어 통상임금의 산입범위에 대한 노사합의는 무효로 보고 있다. 통상임금은 강행규정임은 분명하지만, 강행적 기준임금으로서의 입법기술적 적격성을 흠결하였다는 비판을 면하기 어렵다. 외국의 입법례와 비교할 때 매우 생소하면서도 불합리하게 여겨지는 이유가 여기에 있다.

3. 통상임금제도의 재정립을 위한 입법적 결단이 이루어진다면 그 방향성은 분명하다. 수월성과 명확성이다. 통상임금의 산정에 대한 공식을 규율한다면, 매우 단순하고 계량적이어야 한다. 적어도 추상적이고 일반적인 개념을 해석하여야 하는 수고로움은 덜 수 있도록 해야 한다. 최저통상임금 개념을 입법화하여 최저임금과 마찬가지로 그 금액을 계량적으로 정해 두는 방식을 고려할 필요가 있다. 나아가 노사 간 가산임금에 대한 합의를 존중함으로써 적어도 모호성을 이유로 한 통상임금분쟁의 발생은 예방할 수 있을 것이다. 적어도 오계산 때문에 발생하는 ‘권리분쟁’만큼 소모적인 것도 없다. 노동법은 노사간 분쟁을 해결하는 도구이지, 노사간 분쟁을 유발하는 도구는 아니어야 하기 때문이다.

참고문헌

- 권 혁, “통상임금의 ‘고정성’에 관한 법리 재평가”, 노동법논총 제28집, 2013. 08., 한국비교노동법학회
- _____, “통상임금의 ‘정기성’ 판단법리와 임금정기불의 원칙”, 고려법학 제71호, 2013, 고려대학교 법학연구원
- 노동법실무연구회(최은배, 성준규 집필부분), 『근로기준법 주해 I』 제2판, 박영사, 2020
- 노상현, “통상임금의 개념과 범위의 법제화와 쟁점”, 노동법논총 제31집, 2014. 08., 한국비교노동법학회
- 박지순, 이상익, 통상임금의 이해, 신조사, 2013
- 방강수, “통상임금 법리의 이원화(二元化) — 가산임금 외의 ‘다른 수당’ 산정시의 통상임금 법리 —” 법학논총(한양대) 제36권 제4호, 2019, 한양대 법학연구소
- 이철수, “통상임금에 관한 최근 판결의 동향과 쟁점-고정성의 딜레마”, 서울대학교 법학 제54권 제3호, 2013. 09, 서울대 법학연구소
- 임종률, 『노동법』 제19판, 박영사, 2019
- 하갑래, “통상임금제도의 변화와 과제”, 노동법학 제44호, 2012. 10, 한국노동법학회
- 하경효, 임금법제론, 신조사, 2013
- Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz, 1964
- Fischer, ZfA 2002, S.228 ff.
- Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5.Aufl., 1983

<Abstract>

Study on whether wages are a concept close to conditions

Kwon, Hyuk*

Wages are compensation for labor. Labor and the results of labor provision are distinct. Labor is not a concept that takes results into account. Labor refers to entrusting human labor power to others. Employers can specifically utilize workers' labor power through the right to direct. When labor is provided, the employer must pay wages, but the method of calculating wages changes depending on the time and amount of time the labor is performed. Additional wages must be paid for labor provided at night. If labor is provided on a holiday, additional wages must also be paid. In this way, employers must pay additional wages to workers for night, holiday, and overtime work. The method and means of calculating additional wages at this time is the regular wage. Regular wages are the opposite word of regular work. Additional wages are paid for non-regular work, and the standard for this is regular work. The problem is that the concept of regular wages is ambiguous. Legal disputes that arise due to the fact that the concept of regular wages is ambiguous have a very unique meaning. If both labor and management are peaceful but have to go through a dispute due to legal ambiguity, this is nothing more than the legislator causing labor-management conflict. A typical wage dispute is a fight between employers and workers to get more wages or pay less wages. The Supreme Court, through a full bench decision, conceptually denied the fixity of regular wages. The Supreme

* Professor of Graduate School of Labor Studies, Korea University

Court has explained in its decision that fixity means the prior determination of wages through previous decisions. The Supreme Court has changed that decision on its own. The main content of the case law is that it is possible to attach conditions to wages, but it is still questionable whether the conditions attached to wages can actually be wages. This is because in cases where conditions are attached, there is a higher probability that the purpose of the conditional attachment exists separately. In this regard, it is necessary to examine more closely whether regular bonuses subject to employment conditions are actually wages.

Key Words: Wages, regular wages, additional wages, prior determination, legislative defects, bonuses, instrumental concepts